

1500057-45.2021.8.26.0280

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STF. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri - SP - cep 11760-000

1500057-45.2021.8.26.0280 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500057-45.2021.8.26.0280

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINÍCIUS CÂMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA

Vistos.

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porquanto, no dia 15 de março de 2021, por volta das 19h45m, na Rodovia SP 055, nº 371, área rural, cidade de Pedro de Toledo, comarca de Itariri, o réu, qualificado a fls. 04, trazia consigo, para fins de tráfico, 3.000 (três mil) pinos de cocaína, 2.625 (dois mil seiscentos e vinte e cinco) pedras de crack e 691 (seiscentos e noventa e uma) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Autuado e preso em flagrante (fls. 01), em audiência de custódia o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, em 16/03/2021.

Em 23/03/2021 foi concedida liberdade provisória ao réu.

O réu foi citado, apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida..

Durante a instrução, foi ouvidas quatro testemunhas e, em seguida, interrogado o acusado, mediante sistema de filmagem e gravação de áudio.

Em alegações finais, após análise da prova produzida nos autos, o Ministério Público requereu a procedência da ação e a condenação do réu.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva do delito relacionado ao tráfico de entorpecentes está estampada no boletim de ocorrência de fls. 08/09, auto de prisão em flagrante de fls. 01/2, auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, pelo laudo pericial químico toxicológico de fls. 157/159, a atestar que a substância apreendida se enquadra nos termos da Lei de Drogas, e na prova oral produzida em Juízo. Por seu turno, a autoria delitiva do réu é igualmente comprovada.

A testemunha Boanerges Mendes Galdino Da Silva disse que no dia estava em fiscalização de rotina em frente da base quando foi dada ordem de parada o veículo. Ao fiscalizar o veículo, foi pedida habilitação do condutor e este estava com certo nervosismo. Ao fazer vistoria no veículo no porta malas, foi encontrado um saco preto com certa quantidade de drogas. Não se lembra a quantidade exata. Mas era bastante. Uns três mil pinos de cocaína. O réu falou que tinha buscado as drogas na cidade de Cubatão e que receberia a quantia de R\$ 500, 00 para levar até a cidade de Juquiá. O veículo que o réu dirigia era dele mesmo. Não conhecia o réu dos meios policiais. Resolveu abordá-lo porque abordam veículos para fiscalização. A partir do momento que a pessoa demonstra atitude suspeita fazem fiscalização. O réu se demonstrou nervoso.

A testemunha Thiago Cruz de Lima disse que no dia dos fatos estava em fiscalização em frente a base e foi dado sinal de parada ao réu. Após ele demonstrar certo nervosismo foi feita busca no veículo e encontrada droga. o réu falou que receberia uma quantia de R\$ 500,00 para levar a droga de Cubatão a juquiá, se a testemunha não está enganada.

A testemunha Luciene Corrêa da Silva Paes disse que conhece o réu. Não sabia do que ele trabalhava. Conhecia ele quando ele trabalhava de "Uber". Quando precisava o réu a levava no médico. Contratava o serviço dele ligando para o celular dele, ocasião em que combinavam o preço. Não contratava o réu pelo aplicativo, ligava direto. Pagava ele com dinheiro. Andou com ele várias vezes. Conheceu ele em Ana Dias. Os pais do réu tem uma casa em Ana Dias. A testemunha conhece a família do réu. O réu transportava a testemunha no carro dele.

A testemunha Thaynan Victor disse que conhece o réu do bairro deles. O réu trabalhava como motorista de aplicativo. A testemunha mandava mensagem para o réu por WhatsApp. Usou o serviço dele bastante. Pagava para ele em dinheiro. Usou o serviço dele por um tempo, mas não sabe precisar. Na cidade do depoente tem aplicativo que funciona, como Uber, mas não sabe se funciona. A testemunha usava por WhatsApp. Conhece o réu do bairro onde moram. Não são amigos. Conheceu o réu por alguns amigos, que indicaram o réu. O réu levava a testemunha para banco e mercado. A testemunha usava taxi em Miracatu. A testemunha não tem carro mas o réu tem. O réu que passava o valor. O réu ficava esperando a testemunha no lugar que ela ia.

Interrogado, o réu disse que os fatos da denúncia não são verdadeiros. No dia 15 de março uma pessoa ligou para o réu dizendo que podia buscar ela em Peruíbe e perguntou quanto que o réu cobraria. O réu falou que custaria R\$ 130,00 e foi busca-lo, Chegando em Peruíbe essa pessoa perguntou se o réu poderia buscar outra pessoa em Cubatão e perguntou o preço. O réu falou que não sabia porque nunca tinha ido até lá. Consultou no "google mapa" viu que dava 82 km e disse que poderia fazer a corrida por R\$ 250,00 e o réu foi. Chegando em Cubatão, a pessoa passou a localização de onde o réu tinha que ir. Lá tinha um rapaz desconhecido com um saco preto, falando que era para o réu levar até Juquiá e que se o réu não levasse o rapaz ia o ameaçar, porque o réu não conhecia eles. O réu não teve o que fazer e teve que aceitar. A pessoa falou com o réu que na chegada o pagaria. O réu não teve o que fazer e aceitou. O réu passou em Cubatão, Praia Grande e Itanhaém e quando chegou em Peruíbe o rapaz ligou e perguntou pelo telegram onde o réu estava. a pessoa falou que chegando em Juquiá mandaria a localização do ponto fixo para o réu. Passando por Pedro de Toledo o policial abordou o réu, pediu o documento do carro e o mandou descer. Revistou o carro e achou o saco preto no porta-malas do carro. O policial abriu o saco, achou o entorpecente e deu voz de prisão. A primeira pessoa que ligou para o réu, por whatsapp era um desconhecido e não tinha foto. O réu foi dispensado do ultimo emprego e começou a trabalhar de Uber.

Indagado se não ficou com medo quando uma pessoa desconhecida, sem foto pediu para o réu ir para Peruíbe, disse que não achou estranho porque era acostumado a fazer esse tipo de corrida para transportar pessoas. Indagado novamente, disse que não pegava com frequência corridas de pessoas desconhecidas e sem foto. Essa ele pegou porque era acostumado a fazer corridas até Peruíbe e de Peruíbe até Miracatu. Indagado se depois não pensou em procurar ajuda em vez de transportar a droga, disse que não tentou porque foi ameaçado e a pessoa tinha o número do réu. Indagado porque não avisou a polícia na hora se inclusive tinha as conversas no celular, disse que não tinha o que fazer e ficou nervoso. Disse que tentou explicar mas os policiais não acreditaram. Indagado se então a versão dos policiais era mentira, disse que não e que os R\$ 500,00 recebeu pelo transporte até Cubatão. Não chegou a receber o valor pelo restante do transporte. A pessoa lhe ameaçou e tinha o número do réu. O réu não é usuário de drogas. Nunca transportou drogas antes. As pessoas ficavam sabendo que o réu era motorista de Uber porque tinha um anúncio do carro. Depois dessa situação o réu não sai de casa e trabalha de pintor com medo do ocorrido. Aquelas pessoas procuraram o réu depois dos fatos. O carro era do réu. A quantidade do entorpecente, além da forma de acondicionamento, evidenciam a situação de traficância descrita no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessário que a testemunha tenham, no caso, presenciado atos de mercancia, diante dos núcleos do artigo 33, caput, do diploma legal.

Os testemunhos dos policiais são seguros e harmônicos entre si. As versões apresentadas na fase de inquérito policial e confirmadas em Juízo demonstram as circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, a evidenciar que, no momento, realizava atos descritos no artigo 33 da Lei de Drogas.

Ressalto, neste ponto, que a circunstância de ser a testemunha policial não interfere, negativa ou positivamente, no valor probante de seu relato.

Nesse sentido, julgado desta C. Corte:

"O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal." (TJSP, Des. Walter de Almeida Guilherme, RT 816:548)

Outro não é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello)

Assim, de se concluir que o réu estava com as drogas para o fim de traficância e exerceu ao menos o núcleo "transportar" descrito no artigo 33 da Lei de Drogas. As testemunhas arroladas pela defesa em nada afastaram a conclusão acima, já que limitaram a confirmar que o réu fazia serviço de transporte de pessoas.

Ora, a prática de serviço de transporte de pessoas não é incompatível com o concomitante serviço de transporte de drogas. Aliás, do que se verifica pela experiência, acontece por diversas vezes.

Já a versão do réu, por sua vez, é absolutamente inverossímil.

Primeiro porque narra que aceitou fazer corrida intermunicipal solicitada por pessoa desconhecida que sequer possuía foto de identificação pelo aplicativo do whatsapp.

Segundo porque não é crível que uma pessoa que dispunha de 3.000 pinos de cocaína, 2.625 pedras de crack e 691 porções de maconha, totalizando elevadíssimo valor em mercadorias, entregaria para um desconhecido, como o réu, mediante ameaça de mal injusto e grave, criando o risco do ameaçado levar os fatos ao conhecimento da polícia, inclusive munido de mensagens via aplicativos de conversas que facilmente

identificariam os agentes, em vez de contratar, de forma voluntária, pessoa da confiança deles para o transporte.

Por fim, também não é crível que o réu, além de não ter procurado imediatamente a polícia para noticiar os fatos, não tenha, quando a abordagem, contado essa suposta verdade à polícia, ou que tenha contado e ambos os policiais em Juízo tenham omitido isso.

Assim, não resta dúvida que o réu, dolosamente, transportava as drogas descritas na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Passo, pois, à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, nos termos dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que a natureza e a quantidade da droga extrapolam o normal do tipo. As demais circunstâncias são normais ao tipo. Desse modo, fixo a pena no mínimo legal de 5 anos 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.

Na segunda fase, não havendo atenuante e agravantes a serem consideradas, a pena deve ser mantida no patamar anterior.

Ressalto que afasto a aplicação da agravante da calamidade pública, já que não restou demonstrado que o acusado obteve qualquer vantagem ou facilidade na execução do crime em razão da pandemia do COVID 19.

Na terceira fase, impende observar que o réu é primário, não pesando contra ele antecedentes criminais. Apesar dos elementos existentes nos autos, suficientes à condenação pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não há prova de que se dedique a atividades ilícitas habituais ou que integre organização criminosa, o que é sempre ônus da acusação.

Note-se que eventual dedicação a atividade criminosa não pode ser presumida. Ao revés, deve ser comprovada devidamente através de fatos concretos. Além disso, a quantidade de drogas transportadas por si só não demonstra dedicação à atividade criminosa.

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STF. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER NECESSARIAMENTE OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

3. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser

necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

7. Apenas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas para modulação da fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas para fixação da pena-base.

8. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

9. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se na simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva, e na natureza ou quantidade de droga apreendida, especialmente, quando valorada na primeira fase da dosimetria em evidente bis in idem.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 676.516/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

De rigor, pois, a redução da pena em seu patamar máximo, de 2/3, conforme previsão do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, estabelecido cada dia-multa em 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo, pois não demonstrada situação financeira favorável ao réu.

Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não ser o crime de tráfico privilegiado equiparado a hediondo (HC 118533), nos termos do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena corporal deve ser o aberto, devido à primariedade do agente, à quantidade de pena e à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA como incurso no delito do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, estabelecido cada dia-multa em 1/30 (um trinta-avos) do salário mínimo.

Em se tratando de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, com aplicação de reprimenda inferior a quatro anos em desfavor de quem é primário e não ostenta antecedentes criminais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Cumpra assinalar que o Senado Federal, por meio da Resolução nº 5, de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu a expressão "vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos" do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, haja vista a declaração incidental de inconstitucionalidade proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no HC 97.256/RS no que diz respeito a tal restrição.

Possível, portanto, a substituição da pena corporal pelas penas alternativas. Nesse sentido:

"Agravo em Execução Nulidade da sentença por violação a coisa julgada - Afastamento - Substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos Tráfico de entorpecentes Possibilidade Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal Aplicação da Resolução nº 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal Admissibilidade Agravo improvido" (TJ-SP - EP: 02103444220128260000 SP 0210344-42.2012.8.26.0000, Relator: Pedro Menin, Data de Julgamento: 22/01/2013, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/01/2013).

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, opera-se a substituição por duas restritivas de direitos, porquanto a pena privativa aplicada foi superior a um ano. Dentre as penas alternativas previstas no artigo 44 do Código Penal, entendo mais adequada ao caso em espécie - considerando que a finalidade da pena é a reprovação

e a prevenção do crime - a prestação de serviços à comunidade, cuja eficiência vem sendo enaltecida por estimular reflexão ao condenado relativamente à conduta delituosa e suas consequências, bem como por propiciar benefício direto à comunidade em que vive. A pena alternativa ora aplicada em caráter substitutivo deverá ser cumprida à razão de uma hora por dia de condenação. É facultada a redução do tempo de cumprimento da reprimenda mediante o aumento da carga horária semanal, observada a regra do artigo 46, parágrafo quarto, do Código Penal. A segunda pena alternativa é a proibição de frequentar bares e casas noturnas durante o período da condenação, o que guarda proporcionalidade com o crime praticado, de tráfico de entorpecentes.

Eventuais adequações serão realizadas pelo Juízo das Execuções.

Poderá o réu recorrer em liberdade.

Oficie-se à Delegacia de Polícia para incineração dos entorpecentes, caso ainda não realizada.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100(cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária já concedida.

Transitada em julgado, adotem-se as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil;
2. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da Lei nº. 7.210/84.

Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.

P.I.C.

Itariri, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA